

1006000-09.2022.8.26.0008

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Rubens Pedreiro Lopes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... pelo ocorrido: a CLARO por permitir o furto de seu número de telefone e o FACEBOOK, por não proteger a conta de terceiros fraudadores, dificultando a recuperação pelo verdadeiro titular.

Pois bem.

Com relação ao corréu FACEBOOK, a questão deve ser apreciada sob a Lei nº 12.965/2014, conhecida como "Marco Civil da Internet" (Lei nº 12.965/2014), que, em seu artigo 19, caput e par. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

4ª Vara Cível

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo - SP - cep 03085-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006000-09.2022.8.26.0008 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006000-09.2022.8.26.0008

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Adalho Fregona Neto

Requerido:

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes

Vistos.

ADALHO FREGONA NETO ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e de CLARO S/A. Alega a parte autora ser uma pessoa pública, exercendo ofício como médico (CRM/SP sob nº173485), referência na área de emagrecimento avançado, com credibilidade ímpar. Ocorre que, no dia 11.02.2022, entre 10h e 14h, o autor percebeu a infelicidade de que a conta do seu número de telefone da operadora CLARO havia sido furtada e o perfil profissional no INSTAGRAM havia sido hackeado. A princípio, verificou inconsistências na sua conta referente ao telefone celular. Como estava em uma cidade no interior da Bahia, que não tinha sinal telefônico, no mesmo dia se deslocou a uma cidade vizinha. Entretanto, persistia a ausência de sinal em seu celular. Entrou em contato com a operadora de celular em duas oportunidades (protocolo nº 003225079781175 e nº 003225079795779), sendo informado que não havia qualquer problema em sua linha telefônica. Sem conseguir resolver situação,

deslocou-se até a cidade de Salvador/BA, mais precisamente a um Shopping Center onde existia uma Loja da CLARO e lá permaneceu por cerca de duas horas para tentar resolver o problema. Ao conseguir recuperar o número telefônico, percebeu que sua conta junto ao INSTAGRAM havia sido hackeada. O autor, de imediato, tentou de todos os modos recuperar a conta, porém sem sucesso. Ao conversar com determinado paciente sobre o ocorrido, o autor foi informado que existia uma pessoa especialista (Consultor Digital) em recuperação de contas hackeadas, de nome Cassio Pastrana, o qual cobrou o valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) para recuperar a conta hackeada. Após recuperá-la, foi possível verificar uma série de ações ilícitas e reprováveis para com os seguidores do autor. Além de ofender e debochar da polícia, os fraudadores ainda aplicaram vários golpes envolvendo transferências bancárias. O autor, então, publicou um vídeo esclarecendo o ocorrido. Entende que o golpe sofrido é oriundo e articulado por um conjunto de infratores, os quais as requeridas não tiveram e sequer se deram o trabalho de controlar. Sustenta a ocorrência de violação na prestação de serviços. Alega a ocorrência de danos morais. Destaca que a corre CLARO, apesar de confirmar a fraude na troca do número, não apresentou as informações solicitadas acerca da identificação do infrator. Destaca os danos materiais da ordem de R\$ 5.000,00 para recuperação da conta hackeada, além das transferências realizadas por terceiro, totalizando R\$ 12.500,00. Requer a condenação das corrés ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais alegados, invertendo-se o ônus probatório.

Juntou procuração e documentos (fls. 29/40).

Citado (fls. 50), o corréu FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA apresentou contestação (fls. 54/82), alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor para pleitear valores em nome de terceiros. No mérito, destaca que, pela narrativa da exordial, é possível notar que o acesso a conta do autor ocorreu em razão de clonagem de sua linha telefônica junto à operadora de telefonia (clonagem denominada "SIM SWAP"), de modo que o comprometimento da sua conta no serviço INSTAGRAM ocorreu exclusivamente por agentes externos, logo, não são imputáveis quaisquer responsabilidades ao Provedor de Aplicações do INSTAGRAM. Os usuários, ao ingressarem no INSTAGRAM, tomam ciência de suas funcionalidades a fim de obterem a melhor experiência possível. Nesse espírito, uma das principais preocupações da rede, é - e sempre foi - a de zelar pela segurança e harmonia da aplicação, a fim de prestar o melhor serviço e experiência aos seus usuários. Nos "Termos de Uso", o serviço INSTAGRAM consigna a todos os seus usuários um conjunto de padrões mínimos que deverão ser respeitados, inclusive no que diz respeito à segurança da conta dos usuários e proteção de suas informações pessoais. Também, na mesma seção da "Central de Ajuda", o Provedor de Aplicações do INSTAGRAM se preocupa em detalhar procedimentos de segurança, tal como "autenticação de dois fatores"

(https://help.instagram.com/566810106808145?helpref=page_content), que corresponde a mais um recurso de segurança de senha. não é possível concluir que qualquer impasse para acesso do Autor às suas contas no serviço INSTAGRAM. Desse modo, conclui que não há ato ilícito pelo Facebook Brasil ou pelo Provedor; não há nexo de causalidade entre suas condutas e os eventuais danos ou prejuízos alegados pela parte autora; incidem, in casu, excludentes de responsabilidade sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a impossibilidade de ressarcir o autor pela contratação de terceiro para recuperação da conta. Entende não estar comprovado o dano material. Impugna o pedido de indenização por danos morais, bem como o valor pleiteado. Aponta a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requer o acolhimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Juntou procuração e documentos (fls. 83/100).

Citada (fls. 51), a corré CLARO S/A também apresentou contestação (fls. 113/125), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois não tem qualquer relação com o Facebook. No mérito, afirma que não foi verificado qualquer problema na linha telefônica, de modo que o problema se deu exclusivamente com a conta do autor no aplicativo e eventuais falhas procedimentais de segurança devem apuradas diante da plataforma Facebook. Nega que haja causalidade adequada entre o dano alegado e a conduta da requerida. Destaca, ainda, a culpa exclusiva de terceiro no ocorrido. Considera inexistir prova mínima do dano alegado. Nega a ocorrência dos danos

morais. Busca a improcedência dos pedidos iniciais.
Juntou procuração e documentos (fls. 126/134).
As corrés postularam o julgamento antecipado do feito (fls. 138/139 e 140/141).
Réplica às fls. 143/147.

É o relatório.
Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito é substancialmente de direito, sendo suficientes ao deslinde da controvérsia as considerações tecidas pelas partes e a prova documental já carreada aos autos, sem a necessidade de outras provas para proceder ao julgamento. As partes também não manifestaram interesse na dilação probatória, a corroborar com a possibilidade de antecipação do julgamento. Inicialmente, há de ser afastada a alegação de ilegitimidade da corré CLARO S/A. Isto porque resta claro que o pedido indenizatório se fundamenta em suposta clonagem do chip de telefone do autor, cujo serviço é prestado pela corré CLARO, de modo que há pertinência subjetiva para inclusão da empresa no polo passivo. Com relação à ilegitimidade do autor para postular valores desembolsados por terceiros, entendo que esta matéria envolve o mérito e será analisada oportunamente.

Ausentes demais questões preliminares, passo ao julgamento do mérito. Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora busca ver ressarcido o dano causado pelo fato de seu número de telefone ter sido alvo de clonagem por terceiros e de sua conta profissional no Instagram ter sido hackeada, de modo que ambas as corrés seriam responsáveis pelo ocorrido: a CLARO por permitir o furto de seu número de telefone e o FACEBOOK, por não proteger a conta de terceiros fraudadores, dificultando a recuperação pelo verdadeiro titular. Pois bem.

Com relação ao corréu FACEBOOK, a questão deve ser apreciada sob a Lei nº 12.965/2014, conhecida como "Marco Civil da Internet" (Lei nº 12.965/2014), que, em seu artigo 19, caput e par. único, prevê: "Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material".

Da leitura do dispositivo, conclui-se que não deve haver fiscalização prévia do conteúdo publicado, sob pena de se tratar de censura de conteúdo. A responsabilidade da ré, ao disponibilizar espaço virtual a milhões de usuários, é subjetiva e há evidente impossibilidade de controle prévio. Esse controle deve ser posterior e judicial. Sendo assim, o FACEBOOK apenas poderia ser responsabilizado se, após ordem judicial, não tivesse tornado o conteúdo indisponível ou inerte quanto ao procedimento de recuperação da conta.

No caso, sequer houve pedido de ordem judicial para restabelecimento da conta. Em que pese o autor tenha afirmado que houve dificuldade, tanto que contratou um profissional para lhe ajudar a recuperá-la, não há provas do alegado.

Frise-se que não é possível atribuir ao FACEBOOK o ônus de comprovar que não ofereceu entraves à recuperação da conta, mas era o autor que poderia demonstrar por meio de prints e mensagens que tentou o contato com o requerido e não obteve resposta. Contudo, limitou-se a apresentar apenas o comprovante de transferência a quem supostamente recuperou a conta, não sendo suficiente para atrair a responsabilidade do correquerido.

Também não há que se cogitar falha na segurança da conta, pois o fraudador estava

de posse do próprio número de telefone do requerido, com acesso às verificações de segurança que o sistema exige.

Por outro lado, no que se refere à CLARO S/A, oportuno ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 6º, inc. VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso, a invasão ao perfil na rede social se deu pelo fato de seu número de celular ter sido transferido para um outro chip, vindo a ser utilizado em outro aparelho por terceiro, o que teria bloqueado sua linha. A requerida nega a responsabilidade pelo ocorrido e diz que não foi constatado qualquer problema na linha telefônica do autor.

Com efeito, sendo consumerista a relação entre as partes, nos termos acima expostos, a eventual responsabilidade da ré, por força do artigo 20, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, baseada no risco do negócio, em que se mostra desnecessária qualquer discussão sobre a culpa, mas apenas a demonstração da conduta do autor do fato, dos prejuízos e do liame causal entre estes danos e o fornecimento de serviços defeituoso efetuado.

Note-se, ademais, que, de acordo com o já mencionado artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, cabível a inversão do ônus da prova, desde que sejam hipossuficientes a parte autora e verossimilhantes as suas alegações. Na hipótese, ambos requisitos estão presentes, pois o autor está em patente desvantagem econômica e de acesso a informações sobre os serviços frente à ré, sendo-lhe fornecido apenas dois números de protocolo (003225079781175 e 003225079795779) e suas alegações são plausíveis, afinal a invasão de sua conta na rede social está suficientemente demonstrada.

A respeito do golpe em questão, quando uma linha de celular é ativada, os sistemas da Operadora de Telefonia Móvel fazem a relação entre número de telefone celular (também chamado MSISDN) e número único armazenado no SIM Card (chamado de IMSI). Com o uso, é possível que o cliente peça a troca de SIM Card (no caso de perda de telefone, por exemplo). Nesse caso, a operadora entrega um novo SIM Card para o cliente e desativa o anterior, atribuindo o MSISDN existente/atual a um novo SIMCard (novo IMSI).

No caso do golpe do SIM WAP, terceiros clonam o número de telefone por meio da troca de SIM Card e, após conseguir os dados da vítima nas plataformas sociais, os hackers realizam a mudança do número do celular da vítima para um novo SIM card e, por fim, em posse de um telefone com número celular da vítima, o fraudador consegue concluir autenticações nas instalações de aplicativos, acesso à redes sociais entre outras fraudes que exigem uma etapa de autenticação através do número telefônico. Desta forma, é possível concluir que houve evidente falha na prestação de serviços pela ré, que não garantiu ao seu usuário o uso privativo de sua linha telefônica, não tendo a parte requerida se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, tampouco qualquer excludente de responsabilidade.

Vale ressaltar que fraude praticada por terceiro não constitui causa excludente da responsabilidade do fornecedor, pois compõe o risco próprio de sua atividade, pelo qual é objetivamente responsável. Ademais, ainda que a invasão ao perfil na rede social possa se dar por outros meios, no caso dos autos, bem demonstrou a parte autora que a invasão ocorreu concomitantemente ao bloqueio de sua linha telefônica e a inativação do seu chip, indícios mais que suficientes para reconhecer nexos causal entre a clonagem e o ataque hacker ao perfil.

Nesse contexto, resta demonstrado que a requerida tem responsabilidade pelos danos sofridos pela autora, ainda que parcialmente. Afasto apenas a responsabilidade da ré à reparação pelos danos materiais, haja vista que o valor pago profissional para tentativa de recuperação de sua rede social se deu por sua conta e risco, não sendo responsabilidade da ré a restituição do montante.

Também não há que se falar em ressarcimento pelos valores pagos por terceiros, porquanto, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, não tendo o autor comprovado que se subrogou nos direitos daqueles que tiveram o prejuízo.

Já com relação ao dano moral, a situação vivenciada ultrapassa o mero

aborrecimento. O autor utilizava sua conta como profissional da área da saúde e teve sua imagem abalada diante da conduta dos fraudadores.

Como cediço, a indenização pelo dano moral experimentado tem como finalidade tanto compensar o lesado por seu sofrimento, quanto sancionar o causador do dano, a fim de que se abstenha de praticar outros atos lesivos às pessoas.

Deveras, à indenização por dano moral têm faltado critérios objetivos, predominando no ordenamento pátrio o critério do arbitramento, estabelecendo a jurisprudência e a doutrina que os valores devem ficar a cargo do prudente arbítrio do juiz.

Nessa esteira, o valor da indenização deve atender aos fins a que ela se presta, considerando a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, considerando os parâmetros acima mencionados, fixo, a título de danos morais, o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente (Tabela TJSP) e com juros de 1% ao mês, ambos desde a publicação desta sentença, por entender que não há que se falar em mora antes do arbitramento que já levou em conta o tempo decorrido desde o evento danoso, além do entendimento consolidado por meio da Súmula 362 do STJ ("A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento").

A quantia arbitrada, a meu ver, tendo em conta a situação da requerente, a gravidade e a extensão do dano, proporcionar-lhe-á a devida compensação financeira pelos sofrimentos experimentados, sem que venha constituir fonte indevida de enriquecimento, além de possuir caráter inibitório em relação à conduta perpetrada pelo requerido, a fim de que melhor avalie sua conduta.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda em face de CLARO S/A para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente (Tabela TJSP) e com juros de 1% ao mês, ambos desde a publicação desta sentença, por entender que não há que se falar em mora antes do arbitramento que já levou em conta o tempo decorrido desde o evento danoso, além do entendimento consolidado por meio da Súmula 362 do STJ ("A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento").

Pela sucumbência, arcará o autor com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios do corrêu FACEBOOK, que fixo em 10% sobre o valor da causa e, em razão da sucumbência recíproca quanto à CLARO S/A, condeno as partes (autor e CLARO) ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais cada uma. Em relação aos honorários, considerando o trabalho desempenhado pelos causídicos, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no importe equivalente a 10% do valor atribuído aos danos materiais rejeitados, e esta, por sua vez, ao pagamento de 20% sobre o valor da condenação ao patrono do autor.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil) e após, certificado o necessário, com as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (artigo 1.010, §3º, do Código de Processo Civil).

Para fins de recurso, deverá ser recolhido o preparo no importe de 4% sobre o valor da condenação, se houver, ou caso não haja, ou não seja possível desde logo apurar o montante, sobre o valor atualizado da causa.

Conforme disposto no art. 1.275, §3º, das NSCGJ, em caso de existência de mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, a parte apelante deverá providenciar o recolhimento referente à(s) prova(s) material(ais) anexada(s) ao processo, inclusive mídia(s) de audiência, utilizando a guia do FEDTJ, código 110-4, observando, para tanto, o valor indicado no artigo 3º do Provimento CSM nº 2.516/2019 (DJE, 02/08/2019, Caderno Administrativo, Pág. 02).

Com o trânsito em julgado, tendo em conta o Provimento CG n. 16/2016 e Comunicado n. 438/2016, a parte exequente deverá dar início à execução da sentença (Cód 156 - que fará com que o sistema informatizado cadastre automaticamente o incidente de

Cumprimento de Sentença, para onde as partes deverão, doravante, direcionar todas as peças subsequentes), no prazo de 30 dias, facultado ao exequente incluir em sua planilha de cálculo o valor das custas finais (1% sobre o valor da satisfação da execução, respeitado o mínimo legal de 5 UFESPs vigentes), previstas no art. 4º, III, da Lei nº 11.608/03.

Decorrido o prazo sem providências, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA